

1501347-32.2020.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... que se destinavam, sim, ao tráfico, tanto que já possuía dinheiro proveniente do tráfico em sua posse. Ou seja, as circunstâncias do fato, aliados às máximas de experiências, indicam de forma concludente que a droga era destinada, sim, a ulterior entrega ao consumo de terceiros, deitando por terra a negativa de autoria de parte do acusado, que restou isolada no cenário dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501347-32.2020.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK MORAES DA SILVA

Data da Audiência:

12/01/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Erick Moraes da Silva. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Domingos Andrade de Lima Neto e Renan Winher Freitas arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(^a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos nos autos, tanto em juízo como em solo judicial, os policiais militares narraram toda dinâmica da apreensão das drogas e prisão do acusado. Afirmaram que realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados por um transeunte que dois indivíduos praticavam o tráfico nas adjacências do conjunto habitacional, descrevendo as vestes dos agentes. Diligenciaram e se depararam com os dois indivíduos suspeitos, sendo que o acusado dispensou um objeto ante a aproximação policial, e depois de abordados, constatou-se que a sacola dispensada por Erick continha os pinos de cocaína, ao

passo que com ele havia dinheiro. As palavras dos milicianos revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do agente público; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante. Dessa forma, patente a conduta atribuída ao réu, sendo certo que a quantidade da droga, dividida em porções e acondicionada em unidades embaladas e prontas para a mercancia clandestina, indica claramente que se destinavam, sim, ao tráfico, tanto que já possuía dinheiro proveniente do tráfico em sua posse. Ou seja, as circunstâncias do fato, aliados às máximas de experiências, indicam de forma concludente que a droga era destinada, sim, a ulterior entrega ao consumo de terceiros, deitando por terra a negativa de autoria de parte do acusado, que restou isolada no cenário dos autos. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: Segundo consta na denúncia, o dia 30 de novembro de 2020, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo drogas que supostamente seriam destinadas ao tráfico. Em razão disso foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou sua defesa preliminar. A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 12 de janeiro de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e o réu foi interrogado. Os policiais declararam que estavam em patrulhamento e uma pessoa parou a equipe e informou que duas pessoas praticavam tráfico no conjunto habitacional. Foram até o local e no pátio foi localizado duas pessoas, uma com camiseta vermelha e uma preta. As duas pessoas saíram caminhando. Informam que a pessoa de camiseta preta teria dispensado uma sacola ao solo. As drogas foram localizadas na sacola. Ao ser questionado, o réu negou a propriedade da sacola. O réu, ao ser interrogado, negou que a sacola onde foram localizadas as drogas lhe pertenciam, refutando a acusação. É o relatório. A versão apresentada pelas testemunhas acusatórias não é suficiente para demonstrar além de qualquer dúvida razoável que o Acusado estivesse envolvido na prática do crime de tráfico de drogas. Primeiramente, veja-se que não há indícios suficientes de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas, sendo certo que sua versão não foi infirmada pelo restante da prova coligida. Verifica-se, nesse ponto, que o Acusado, desde a fase policial, nega peremptoriamente ser o proprietário da droga localizada, mantendo a mesma versão desde a fase policial (fls. 7). Por outro lado, as testemunhas acusatórias narram que a droga não foi apreendida com o réu, mas em uma sacola que supostamente estaria em sua posse. Além disso, é preciso ponderar que o Acusado não teria sido avistado em atividade típica de traficância, já que inexistiu a identificação de possíveis usuários. Ainda, segundo os próprios policiais, não houve campana, de modo que inexistiu qualquer observação prévia que pudesse concretizar a alegação de que o acusado estava atuando na venda de entorpecentes. Ante ao exposto, entende-se que o cotejo da prova no caso concreto não satisfaz o standard probatório apto à condenação do Acusado, razão pela qual se requer a improcedência da ação penal, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, em respeito ao princípio da eventualidade, passa-se à análise da dosimetria da pena a ser imposta ao acusado. Na primeira fase, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de requisitos capazes de exasperá-la, nos termos do art. 59 do Código Penal. Muito embora o artigo 42 da Lei de Drogas estabeleça como critério para a dosagem da pena a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, é impossível a aplicação de tal norma, na medida em que é difícil avaliar qual quantidade e quais variedades de drogas seriam suficientes para justificar a aplicação da causa de diminuição abaixo do máximo estabelecido em lei. Assim, a inexistência de tal parâmetro faz com que a aplicação de pena seja feita de maneira completamente arbitrária. Na segunda fase, não incidem agravantes, haja vista a primariedade do acusado. A agravante de calamidade pública descrita na denúncia deve ser afastada, uma vez que é indispensável a prova do nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento

jurídico. Na terceira fase, de rigor a aplicação do redutor do tráfico, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Vejamos: Veja-se que não ficou comprovado nos autos que se dedique a práticas criminosas ou que integre organização criminosa, preenchendo então, todos os requisitos do redutor. Aqui, deve ser observada a regra de tratamento que emana da presunção do estado de inocência, não podendo se admitir que processos ainda em tramitação sejam utilizados para presumir-se a dedicação do Réu em atividades ilícitas. Com efeito, o fato de o Acusado responder a outro processo não o impede de receber o redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, com base no princípio da presunção do estado de inocência que somente é afastado com condenação judicial definitiva, nos moldes da mais recente interpretação do E. Supremo Tribunal (HC 187.180/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. Data de julgamento: 19/06/2020). Com efeito, em consulta aos autos n. 1501051-73.2021.8.26.0571, verifica-se que se trata de feito ainda em tramitação, para apreciação do recurso de apelação defensivo. É justamente por essas razões, amparadas em precedentes da E. Suprema Corte, que se requer a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime inicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal, requer seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Isso porque, a fixação de regime fechado como decorrência automática do disposto no artigo 2º da Lei n. 8.072/90 contraria o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Habeas Corpus nº 111.840, em sessão realizada no dia 27 de junho de 2012, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado. De tal forma, ante as peculiaridades do caso em tela, claro está que não há razão para a determinação de regime fechado, ainda que não se aplique o redutor em seu grau máximo. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo ao cumprimento da pena em regime inicialmente aberto. Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o artigo 44 foi considerado inconstitucional pelo E. STF (HC n. 97.256/RS), o que motivou a expedição da Resolução n. 05, de 2012, do Senado Federal, suspendendo, nos termos do art. 52, X, da CF a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante do exposto, requer sejam acolhidas as

teses defensivas, nos termos da fundamentação supra. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais, por se tratar o acusado de pessoa hipossuficiente nos termos da lei. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Vistos. ÉRICK MORAES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, c.c. o art. 61, inc. II, alínea “J”, do Código Penal, porque, no dia 30 de setembro de 2020, em período de anormalidade – Pandemia, por volta das 11 h e 30 min, no conjunto habitacional localizado na Rua Wenceslau Braz, n. 2090, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e seis porções de cocaína, com peso de 3,69 gramas. O Réu foi notificado, fls. 130, e apresentou defesa preliminar, fls. 141/142. A denúncia foi recebida, fls. 143/144, e o Réu, citado por edital, fls. 172. Iniciou-se a instrução, o MP requereu o prosseguimento do feito, mas, por outro lado, a Defesa insistiu na suspensão, e, diante da citação ficta, foi determinada a suspensão dos autos com fundamento no art. 366, na oportunidade foi decretada a prisão preventiva, fls. 175/176. O mandado de prisão foi cumprido, fls. 188/190, na sequência o Acusado foi citado pessoalmente, fls. 210. Em audiência de continuação, foram ouvidas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do Réu (gravação por videoconferência). Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a

absolvição e a aplicação de benefícios. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 10/12, nos Autos de Exibição e Apreensão, fls. 13/14 e fls. 15, bem como no Laudo de Constatação, fls. 34/35 e de Exame químico-toxicológico n. 320.184/2020, fls. 90/92, constatando-se a presença do princípio ativo cocaína. Domingos Andrade de Lima Neto e Renan Winher Freitas, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento quando foram parados por uma pessoa, a qual noticiou que dois indivíduos, um com a camiseta vermelha e o outro com a camiseta preta, praticavam tráfico de entorpecentes; foram ao local e encontraram ambos, o Réu estava com a camiseta preta e, ao ver os policiais, dispensou algo e ambos entraram no bloco do prédio; os policiais conseguiram efetuar a abordagem e encontraram, com o Réu, um celular e dinheiro em notas diversas, e, com Gilson, uma nota de R\$ 50,00; os policiais voltaram ao local onde o Acusado tinha dispensado a droga e encontraram um plástico transparente com vinte e seis porções de "cocaína"; o Réu negou a posse das drogas e Gilson disse que estava ali para fazer uma mudança. Erick Moraes da Silva, Réu, ao ser interrogado, disse que estava do outro lado com outro rapaz, iria prestar auxílio na mudança, entretanto, ao olhar para trás viu os policiais, que o abordaram; com o Réu houve localização de dinheiro e os policiais disseram que o liberariam se nada de ilícito fosse encontrado; os policiais acionaram reforço e algum tempo após os policiais voltaram com os entorpecentes. Confrontando-se a prova coligida e de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu era o proprietário dos entorpecentes, destinados à venda, uma vez que ele, ao ver os policiais, dispensou no chão um saco no interior do qual havia vinte e seis pinos de "cocaína", com peso de 3,69 gramas, drogas que, pela quantidade de porções, eram destinadas ao comércio ilícito. Ademais, houve apreensão de dinheiro, fruto de vendas pretéritas, o que se infere das circunstâncias e da ausência de demonstração de origem lícita. Não se olvida ainda que, no celular portado pelo Réu, foram localizadas fotos de entorpecentes, dinheiro em grande quantidade e conversas próprias do comércio ilícito. Nas fls. 96/117 foi juntado o Relatório de Análise n. 345.867/2020 no qual constam diversas mensagens e algumas fotos. O Réu negou a acusação, mas sua versão restou isolada e inverossímil. Não havia outra razão para o Réu estar naquele local, com aquela quantidade de drogas, exceto a prática do tráfico de entorpecentes. As testemunhas não têm motivos para incriminar um inocente. Para que seja valorada a veracidade ou idoneidade do relato policial, não há necessidade de confirmação do apurado por pessoa estranha aos quadros da Polícia. Absurdo seria admitir-se situação contrária. Não se conhece razão plausível para que os policiais arquitetassem diabólico plano visando incriminar este Réu, apontando-a como autor dessa espécie de crime. Tudo indica que os policiais agiram com lisura e, por certo, não se poderia desacreditar o relato de cada qual, uma vez que apenas tais agentes é que presenciaram e participaram da diligência de localização da droga, não se podendo entender como suspeitos aqueles que são investidos de poder para tal função. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Não seria lógico o Estado contratar agentes para a segurança pública, investindo-os de parcela do poder estatal e, ao serem chamados a Juízo, não lhes emprestar credibilidade. Os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Destarte, o Réu trazia consigo substâncias entorpecentes, conduta esta que configura a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação

múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do Agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Conforme se verifica na certidão de fls. 41/43, o Réu possui procedimentos com extinção da punibilidade e absolvição, destarte, as circunstâncias judiciais são favoráveis, assim fixo a pena - base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: A agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "j", não pode ser acolhida. Com efeito, a incidência da agravante da calamidade pública exige que o agente tenha se aproveitado consciente e voluntariamente de circunstância que implique maior gravidade, e não há nexo de causalidade entre a ofensa ao bem jurídico e a pandemia do novo coronavírus. Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa "empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo", pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar ÉRICK MORAES DA SILVA, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Decreto a perda dos valores e dos bens apreendidos. Deixo de condenar o Réu nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu preso ao processo, porém,

neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição, registrando-se que somente estava preso em razão do descumprimento das medidas cautelares fixadas, fls. 176. Expeça-se alvará de soltura, com urgência. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 12 de janeiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA